

1502468-66.2021.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Maria da Conceição Pinto Vendeiro

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/03/2022

... papéis com anotações de contabilidade do tráfico.

Danillo (policial), em juízo, informou que receberam uma denúncia anônima que um homem negro, com 2,0 m de altura, estaria realizando tráfico. Foram até o local, viram o réu que tinha as mesmas características, o abordaram quando descia a escada caracol da residência. O réu confessou o tráfico, dizendo que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

3ª Vara Criminal

Avenida Sete de Setembro, 399, . - Vila Conceição

CEP: 09912-010 - Diadema - SP

Telefone: (11) 4056-6600 - E-mail: diadema3cr@tjsp.jus.br

1502468-66.2021.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1502468-66.2021.8.26.0537 Controle nº 14/2022

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCELO DE LIMA BRITO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria da Conceição Pinto Vendeiro

VISTOS, ETC.

MARCELO DE LIMA BRITO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06, porque no dia 16 de dezembro de 2021, por volta das 17:00 horas, na Avenida Casa Grande, n.º 01, e na Travessa Anita Garibaldi, Bairro Casa Grande, guardava, para consumo de terceiros, maconha, cocaína e "crack", drogas que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva na audiência de custódia (fls. 78/80).

Foi apresentada defesa prévia (fls. 101/102), sendo recebida a denúncia em 28.04.2021 (fls. 111/112). Na instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, ocorrendo desistência quanto à faltante. O réu foi interrogado no

final, em razão do princípio da ampla defesa e conforme entendimento do STF de que o art. 400 do CPP se aplica aos ritos especiais.

A Dr.^a Promotora de Justiça requereu a procedência da ação por entender estarem provados os fatos descritos na denúncia, com aumento da pena pela quantidade de drogas, que sejam considerado os antecedentes e a agravante da reincidência, fixação de regime fechado e que seja afastada a aplicação do art. 33, §4.º. por ser reincidente.

O Dr. Defensor Público requereu a absolvição por insuficiência de provas ou em caso de eventual condenação, que seja considerada a confissão informal e fixado regime semiaberto diante da detração penal.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Na fase policial, o acusado permaneceu calado (fls. 06/07). Em juízo, negou ter praticado o crime. Disse que saiu da casa de seus filhos (Itaquera), veio de ônibus, ia para o Terminal Piraporinha para chegar em Parelheiros e foi abordado pelos policiais quando fumava um "baseado" na rua. Informou que tem condenações apenas por roubo. Tem 2,03 cm. de altura e possui um salão de cabeleireiro em Santo Amaro.

Os policiais, na fase extrajudicial (fls. 02/05), disseram que se dirigiram até uma viela da Travessa Anita Garibaldi, a fim de averiguar denúncia anônima dando conta de que um homem "afrodescendente", medindo cerca de 2,00 m de altura, integrante de facção criminosa de São Paulo e recém egresso do sistema penitenciário, estava traficando drogas no local. Relataram que ao chegar no local se depararam com o réu, que possuía as mesmas características físicas informadas pelo denunciante anônimo, em frente a um cortiço. Falaram que abordaram o réu, o qual informou que esteve preso por 10 a 15 anos e confessou que estava traficando drogas. Afirmaram que efetuaram buscas no cortiço em que o réu estava morando, que este franqueou a entrada, localizaram um mochila contendo drogas, além de um caderno e papéis com anotações de contabilidade do tráfico.

Danillo (policial), em juízo, informou que receberam uma denúncia anônima que um homem negro, com 2,0 m de altura, estaria realizando tráfico. Foram até o local, viram o réu que tinha as mesmas características, o abordaram quando descia a escada caracol da residência. O réu confessou o tráfico, dizendo que armazenava as drogas dentro da casa (barraco) e autorizou que entrassem. A casa estava aberta, sem móveis e uma mochila no chão com drogas e contabilidade do tráfico. Não conhecia o réu anteriormente. Havia em torno de 700 porções de drogas (maconha, cocaína e "crack").

O depoimento judicial do policial Higor foi no mesmo sentido, o qual esclareceu que a denúncia era que o réu (afrodescendente com 2,0 m de altura e indicava o local) distribuía drogas. Informou que não conhecia o réu anteriormente. A escada caracol só levava até o imóvel onde foram localizadas as drogas em uma mochila. Havia peças de roupas e calçado no chão, talvez um lençol, mas não havia móveis, nem eletrodomésticos, aparentemente ninguém morava no local e se destinava apenas para armazenamento das drogas.

No mesmo sentido foi o depoimento judicial do policial Marcus, o qual acrescentou que ao terminar a escada caracol (que o réu estava descendo) já está na porta do cortiço, onde havia um monte de roupas, tênis, lençol, colchonete jogados no chão. As drogas foram achadas numa mochila no chão desse imóvel. O réu confessou e disse que as drogas estavam na mochila. É uma viela com quartos embaixo e a denúncia era que tinha uma escada caracol que dava no local onde havia drogas.

O fato de a testemunha ser policial não a torna impedida ou suspeita (STF, RTJ 68/64 e 168/199), estando seus depoimentos em consonância com o conjunto probatório.

"PROVA- Declaração da vítima e depoimento de Policiais - Eficácia:

As declarações prestadas pela vítima e os depoimentos de Policiais, se não confrontados por nenhum elemento que indique sua invalidez são provas absolutamente legítimas para sustentar um decreto condenatório, uma vez que o ofendido, por desconhecer o acusado, não tem razão para levianamente incriminá-lo, se inocente; e os Milicianos apenas pela função que exercem não podem ter suas afirmações

comprometidas, já que não possuem interesse na condenação" (Apelação n.º 1.301.549/7- 11.ª Câmara - j. 24.06.02, cf. Ementário do TACrimSP n.º 35, p. 24). A quantidade de drogas apreendidas (fls. 12 - 107 porções de maconha, 499 invólucros de cocaína e 126 unidades de "crack"), e diversidade (maconha, cocaína e "crack"), aliados à falta de comprovação de ocupação lícita, o que é incompatível com a condição de usuário e, ainda, considerando que estava dividida em invólucros, bem como os depoimentos dos policiais demonstram o tráfico, pois não teria como adquirir essa quantidade se não fosse traficante.

Segundo a jurisprudência:

"Ainda que se trate de réu viciado no uso de tóxico, a apreensão de grande quantidade da erva em seu poder, revela o objetivo de sua comercialização" (RJTJSP 75/343). Nesse sentido: RT 538/380.

"Tráfico de maconha- Quantidade da erva apreendida, aliada a outras circunstâncias, que induz à certeza da destinação ao comércio" (RJTJSP 97/492). No mesmo sentido: RJTJSP 123/473.

Irrelevante que não tenham sido presenciados atos de mercancia, posto que denunciado pela conduta de guardar para consumo de terceiros.

A negativa judicial do réu está isolada nos autos, posto que alegou que passava por Diadema e foi abordado quando fumava um baseado, mas nada provou como lhe incumbia nos termos do art 156 do CPP e sua versão foi desmentida pelos policiais no sentido de que foi abordado no local indicado pela denúncia anônima, o réu tem 2,03 de altura (acima da média brasileira), confessou informalmente e ainda apontou onde estavam as drogas. O réu não demonstrou o que fazia em Diadema. Não faz o menor sentido o trajeto que informou, ou seja, sair de Itaquera em direção a Parelheiros (ambas em São Paulo) e passar por Diadema.

Portanto, não é caso de absolvição como requerido pela defesa.

Não é caso de desclassificação para o crime do art. 28, porque a quantidade e diversidade de drogas apreendidas em poder do réu (107 porções de maconha, 499 invólucros de cocaína e 126 unidades de "crack") demonstram que se destinava ao tráfico.

Assim, impõe-se a condenação do acusado, posto que a materialidade está provada pelo laudo de constatação (fls. 15/17) e laudo definitivo (fls. 139/141).

Passo a individualizar a pena a ser aplicada ao acusado, que segundo consta dos autos é reincidente (fls. 61/63 - proc. 19689-26.2013, proc. 37594-88.2006, proc. 78248-83.2007 - penas privativas de liberdade julgadas extintas em 11.02.21 - fls. 73 - e fls. 63 - proc. 100166-94.2017 - em cumprimento de pena - fls. 75).

O art. 5.º inc. XLVI da Constituição Federal prevê que "a lei regulará a individualização da pena" e o art. 61, inc. I, do Código Penal determina que a reincidência é circunstância agravante da pena.

Conforme R.E. 723.211, Rel Min. Ricardo Lewandowski, j. 25.06.13:

"O Plenário desta Corte, no julgamento do RE453.000/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, no dia 4/4/2013, em regime de repercussão geral, julgou o mérito do tema 114 e negou provimento ao RE que alegava a inconstitucionalidade do agravamento da pena em virtude da reincidência, consolidando o entendimento de que não configura bis in idem.

Desse modo declarou ser constitucional a aplicação do instituto da reincidência como agravante da pena em processos criminais (art. 61, I, do Código Penal).".

Assim, a reincidência será considerada como circunstância agravante.

Levando em conta as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base para o tráfico, em razão da quantidade média de drogas (fls. 12 - 107 porções de maconha, 499 invólucros de cocaína e 126 unidades de "crack"), em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, à razão mínima por inexistirem elementos quanto à real situação econômica do acusado. Aumento a pena de 1/6 pela reincidência. A confissão informal não caracteriza a atenuante legal, já que não o fez nem na fase policial, nem em juízo. Ademais, ainda que fosse considerada a reincidência seria preponderante (quatro condenações).

O réu não faz jus à redução do art. 33, §4.º, porque é reincidente e, portanto, não preenche um dos requisitos legais (não é primário) que são cumulativos.

Não se trata de tráfico privilegiado, pelo que não incide no caso em tela o

decidido no HC 596.603 do STJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. em 08.09.2020.

O regime inicial de cumprimento da pena é o fechado, pois conforme prevê o art. 33, §2º, "b" e "c" só se aplicam regimes mais brandos ao "condenado não reincidente". As circunstâncias não são favoráveis, pois é multirreincidente, pois possui quatro condenações por roubo (Fls. 61/63 – proc. 19689-26.2013, proc. 37594-88.2006 e proc. 78248-83.2007 – penas privativas de liberdade julgadas extintas em 11.02.21 – fls. 73; fls. 63 – proc. 100166-94.2017 – em cumprimento de pena – fls. 75), o que denota personalidade voltada para crimes, os quais são seu meio de vida, uma vez que sequer provou possuir ocupação lícita e, ainda, houve aumento da pena pela quantidade de drogas. Trata-se de crime de extrema gravidade, uma vez que causa dependência física e psíquica atingindo inúmeros usuários, provocando perda de emprego, envolvimento em delitos para comprarem drogas, venda de bens inclusive de familiares para satisfação do vício, acarretando efeitos deletérios para a sociedade.

Inviável a conversão em restritiva de direitos ou "sursis" diante do montante da pena e por ser reincidente (Fls. 61/63 – proc. 19689-26.2013, proc. 37594-88.2006, proc. 78248-83.2007 – penas privativas de liberdade julgadas extintas em 11.02.21 – fls. 73 – e fls. 63 – proc. 100166-94.2017 – em cumprimento de pena – fls. 75).

Inaplicável o disposto no art. 387, §2.º, do CPP, diante de sua inconstitucionalidade por violar os princípios da individualização da pena, do juiz natural e da igualdade, já que a fixação da pena e regime estão previstos nos arts. 33 e 68, ambos do Código Penal (norma de direito material), sendo que a progressão de regime deve ser apreciada pelo juiz da execução de acordo com o art. 112 da LEP que é lei especial e prevalece sobre a geral, ou seja, "Lex specialis derogat generali" (Lei especial derroga a geral), não se justificando que o preso provisório possa obter tal benefício sem preencher os requisitos da LEP. Ademais, havendo recurso será expedida guia de recolhimento provisória, pelo que não haverá qualquer prejuízo, pois a progressão será apreciada pelo juízo competente. Além disso, sequer preenche o lapso temporal para tanto (preso em 16.12.21, pelo que ainda que considerado 2/5 só ocorreria em 04.09.24).

Por outro lado, "ad argumentandum", ainda que se considere a detração conforme entendimento do STJ, o fato é que o regime não está atrelado apenas à pena, mas também às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, pelo que diante da reincidência (circunstância judicial agravante), bem como pela quantidade de drogas apreendidas, não é recomendável outro regime diverso do acima fixado.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação e, em consequência, CONDENO MARCELO DE LIMA BRITO à pena 6 (SEIS) ANOS, 9 (NOVE) MESES e 20 (VINTE) DIAS de DE RECLUSÃO, INICIALMENTE NO REGIME FECHADO e 680 (SEISCENTOS E OITENTA) DIAS-MULTA, à razão mínima, por se achar incurso no art. 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06.

Tendo em vista que o réu foi preso em flagrante por crime equiparado aos hediondos previsto na Lei n.º 8072/90, bem como por estarem presentes os requisitos da preventiva, sendo crime de extrema gravidade, fazendo-se necessária a prisão para garantia da ordem pública para evitar a prática de novos crimes de gravidade e para assegurar a aplicação da lei penal, posto que nada há que o vincule ao distrito da culpa (não comprovou residência fixa nem ocupação lícita), conforme decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva (fls. 78/80), e é incabível qualquer benefício, recomende-se na prisão em que se encontra.

Sem custas (Lei n.º 11.608/03), por ser beneficiário da Assistência Judiciária (art. 5.º, inc. LXXIV, da Constituição Federal; STF- RE 313348 AgR/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 15.04.03).

Quanto ao caderno, às folhas de caderno manuscritas e à mochila marca "Mapeng" apreendidas (fls. 12), já periciadas (fls. 137/138 e 142/143), tendo em vista que não possui valor econômico, oficie-se desde já informando que não interessa mais aos autos, podendo ser eliminadas.

Transitada esta em julgado, lance-se o nome do acusado no Rol dos Culpados, oficie-se para incineração da droga mantida para contraprova (fls. 82) e providencie-se o cálculo da multa, abrindo-se vista às partes.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Façam-se as anotações e comunicações de praxe.

Diadema, 24 de março de 2022.

MARIA DA CONCEIÇÃO PINTO VENDEIRO

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA